

1500661-33.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANNA SYLVIA RODRIGUES E SILVA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... transporte da droga não comprova o tráfico, não havendo ainda qualquer prova do envolvimento pretérito do réu com a traficância. Subsidiariamente, sustentou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500661-33.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500661-33.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213388/2022 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 26589556 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2213388 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARY DIANE ALBANO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANNA SYLVIA RODRIGUES E SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de MARY DIANE ALBANO e GELCI SIMÕES, em que lhes são imputadas as condutas dos artigos art. 35 e art. 33, "caput", ambos da Lei nº11.343/06, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta, em data e local incertos, mas certo que antes do dia 05 de agosto de 2022, os réus, qualificados às fls. 08 e s fls. 10,

respectivamente, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 05 de agosto de 2022, por volta de 16h45, na Rodovia SP 425, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, MARY DIANE ALBANO e GELCI SIMÕES, transportavam 260 quilos de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

Em audiência de custódia (fls. 69/72), foi convertido o flagrante em prisão preventiva.

A denúncia foi recebida (fls. 114/115) em 23 de agosto de 2022.

Citados (fls. 168/170), os réus apresentaram resposta a acusação (fls. 175/180).

Designada audiência de instrução e julgamento para a presente data (fls. 189/191), foram ouvidas duas testemunhas e interrogados os réus.

Em manifestação oral, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para incluir a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, tendo as partes informado não possuir outras provas e a desnecessidade de reinquirição das testemunhas e novo interrogatório (fls. 217/219). Em alegações finais, o MP requereu a procedência da ação penal, não sendo crível que a co-ré não tivesse ciência da existência da droga, haja vista o peso do carro diante da grande quantidade de entorpecentes e as mensagens enviadas de seu telefone celular. Quanto à dosimetria da pena, apontou que a ré Mary é primária e o réu Gelci é reincidente (fls. 130/137), pugnando ainda pela fixação da pena acima do mínimo legal em razão da grande quantidade de drogas apreendida.

Em alegações finais, a Defesa da ré Mary Diane Albano pugnou pela absolvição pela ausência de provas, haja vista que ela desconhecia que o marido transportava a droga e acreditava que a viagem ocorria em razão de uma proposta de trabalho do marido, versão esta corroborada pelo depoimento do co-réu e pelos documentos de fls. 64/68. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor do art. 33, parágrafo quarto, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em alegações finais, a Defesa do réu Gelci Simões requereu a absolvição por ausência de provas, haja vista que o mero transporte da droga não comprova o tráfico, não havendo ainda qualquer prova do envolvimento pretérito do réu com a traficância. Subsidiariamente, sustentou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2); Boletim de Ocorrência (fls. 12/16), auto exibição de apreensão (fls. 17/18), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 19/20), fotografias (fls. 35/46), laudo pericial toxicológico (fls. 101/103, 139/141) e dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 142/166).

A autoria também restou parcialmente comprovada.

O policial militar Alan Junior dos Santos relatou que, durante patrulhamento em via

conhecida pelos policiais por ser utilizada para o tráfico de drogas e contrabando, a viatura policial foi ultrapassada por um veículo, em alta velocidade e com o compartimento traseiro visivelmente rebaixado, o que levou os policiais a abordarem o carro. Ao realizarem a abordagem, o casal demonstrou nervosismo e então resolveram revistar o veículo, oportunidade em que foi encontrada a droga no banco traseiro. Ainda de acordo com os policiais, os réus disseram que pegaram a droga no Paraná, na cidade de Umuarama/PR com, com destino a Presidente Prudente, e iriam receber o valor de R\$ 10.000,00 pela droga. Disse ainda que os dois réus confirmaram que sabiam que a droga estava no carro.

O policial militar Fábio de Oliveira Macedo afirmou que estava em patrulhamento na rodovia quando o veículo conduzido pelo réu passou pela viatura e despertou a atenção da equipe, que já conhecia a via por ser usada para tráfico e contrabando; que resolveram abordar o casal e encontraram no veículo 258 quilos de maconha.

Interrogada, a ré MARY DIANE ALBANO disse que não sabia que o companheiro estava transportando drogas; que possui transtornos psíquicos (é depressiva suicida) e ajuizou uma ação junto ao INSS para obtenção de benefício; que apenas parte dos fatos narrados é verdade; que o marido chegou em casa e a chamou para fazer uma viagem a São Paulo porque não tinha com quem deixá-la; que por isso ela foi com ele; que a polícia então parou o carro com a droga; que o marido pegou o carro com outra pessoa; que não tem nenhum envolvimento; que o marido não explicou a ela nada; que não perguntou o que ele estava transportando, apenas entrou no carro e foi; que até no serviço ela vai com ele porque ele não a deixa sozinha; que ele tem costume de andar em alta velocidade, por isso não estranhou nada; que não sentiu cheiro nenhum; que no caminho o marido a orientou a enviar mensagens para uma pessoa de nome Alex informado onde estavam e o local por onde passavam; que nunca tinha ido a Presidente Prudente.

Interrogado, o réu Gelci Simões disse que os fatos são parcialmente verdadeiros, pois no momento da abordagem não falou nada aos policiais; que foi pego com a droga e saiu com ela do Paraná, porém não sabia para onde ia; que a esposa não sabia de nada; que as mensagens enviadas pelo celular foram para a pessoa de Alex e enviadas pela esposa a seu pedido; que estava avisando as distâncias porque não sabia onde estava e a pessoa estava instruindo.

É a prova dos autos.

De acordo com a denúncia, os réus transportavam no interior do VW Voyage, placa IQS3D13, a droga mencionada na inicial. No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento rural em rodovia conhecida como rota para a prática dos crimes de tráfico de drogas e contrabando, quando foram ultrapassados pelo veículo VW Voyage, placa IQS3D13, que era conduzido pelo réu acima da velocidade permitida e trazia como passageira a ré, razão pela qual decidiram abordá-los. Na abordagem, os réus demonstraram nervosismo e apresentaram informações desconhecidas sobre a origem e destino da viagem. Durante revista no veículo, foram localizados no porta-malas e no banco traseiro, escondido sob uma coberta, aproximadamente 260 quilos de maconha. Também foram apreendidos em seu poder dois telefones celulares e a quantia de R\$914,00 (novecentos e catorze reais).

Os fatos narrados na denúncia, quanto ao transporte da droga, foram confirmados pela prova produzida em juízo. Os réus foram presos em flagrante, na posse da droga. Os policiais militares detalharam a abordagem e a apreensão do entorpecente. Os depoimentos prestados pelos policiais, cuja credibilidade é a mesma à de qualquer testemunha em juízo, são coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas acostadas aos autos, como os autos de exibição e apreensão das drogas, veículo e telefones celulares (fls. 17/18), além de fotografias (fls. 35/46). Anoto que, embora tenham sido juntadas na fase do inquérito, são elementos de natureza irrepetível e por isso submetido, excepcionalmente, ao contraditório diferido.

Ademais, as mensagens registradas no telefone celular dos réus (laudo pericial 255.469/2022, fl. 142, Imeis à fl. 148, atribuídos ao réu no auto de apreensão à fl. 17 e com conta de whatsapp vinculada à co-ré, fl. 148) demonstram de forma inequívoca sua atuação para transportar as drogas entre os estados, havendo troca de mensagens acerca do trajeto e transporte da droga e orientações sobre pontos de parada. Inclusive, à fl. 153, consta a seguinte transcrição: “Alex, sujô. A polícia mandou nois para”.

Assim, não prospera a tese defensiva relacionada à co-ré de que não tinha ciência do transporte da droga, pois as mensagens enviadas pelo seu celular, por ela, conforme informou o réu em interrogatório, ainda que a seu pedido, denotam o conhecimento da situação. Além disso, o carro rebaixado em razão do peso da grande quantidade de droga (260 quilos de maconha), que inclusive chamou a atenção dos policiais, torna ainda mais inverossímil a versão da co-ré.

Por fim, o réu confessou os fatos e admitiu que estava transportando a droga em troca de dinheiro, ainda que tenha buscado inocular a companheira.

Portanto, a autoria em relação ao transporte da droga recai sobre ambos os réus.

Por outro lado, não prospera a acusação em relação à associação para o tráfico. O delito em questão descreve a conduta de “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”. No caso em tela, o delito para o qual os réus teriam se associado é o do art. 33.

Trata-se de delito plurissubjetivo ou de concurso necessário, exigindo o legislador o mínimo de 2 pessoas para configuração, computando-se os inimputáveis. Prescinde, para sua tipificação, da apreensão das drogas e seu exame pericial. Há especial fim de agir na associação em questão: finalidade específica de cometer crimes de tráfico. Além disso, a associação deve ser permanente, estável e contínua.

Sobre a definição do elemento subjetivo do tipo, Guilherme de Souza Nucci afirma que é necessário o ânimo de associação, consistente no propósito de manter uma meta comum (Em Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Editora RT, 2006, pág. 785). No acórdão da apelação 1501586-96.2019.8.26.0530, relatado por Nucci, em que houve absolvição em sede recursal do delito de associação para o tráfico, assim se manifestou autor, acerca da estabilidade e permanência:

“É necessário distinguir-se o crime em questão do simples concurso de pessoas. Embora em ambos se exija liame subjetivo, o vínculo psicológico é diverso. No concurso de agente, o vínculo refere-se à prática de um ou mais crimes determinados, os criminosos somam esforços para a prática de delito ou delitos já individualizados pelo grupo. Na associação, por outro lado, o vínculo subjetivo não se relaciona a um ou alguns delitos de tráfico de entorpecentes; em verdade, o número de delitos a serem praticados é indeterminado, os quais serão praticados enquanto perdurar a associação. Diz-se, destarte, que o concurso de agentes é ocasional e transitório, enquanto a associação é estável e permanente”.

De acordo com Cléber Masson, embora o caput do art. 35 faça menção à expressão reiteradamente ou não, a jurisprudência tem decidido “acertadamente pela imprescindibilidade da estabilidade e permanência para a caracterização do delito” (em Código Penal Comentado, 9 ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, pag. 1212). A propósito:

“Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 432.531/MG, 5ª T., Rel. Min. Jorge Mussi)”.

Assim, não é possível, a partir de determinada apreensão de drogas ou

ocorrência de ou outro episódio de tráfico, se presumir a existência da estabilidade, devendo o Estado investigar os fatos. Logo, a absolvição é medida que se impõe, pois não há provas do vínculo associativo.

Passo à tipificação da conduta.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é daqueles denominados 'tipo misto alternativo', que apresenta multiplicidade de verbos nucleares, sendo despendida a comprovação da comercialização, bastando a prática de quaisquer dos verbos cernes não sejam dotados do fim específico de uso pessoal. No caso em liça, o agir atribuído ao réu é "transportar" para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

Por sua vez, a finalidade da traficância é verificada pelas circunstâncias objetivas dos fatos, pois não é possível aferir, no íntimo do agente, a sua finalidade. A elementar do tipo penal em questão, nos casos em que não houve a efetiva comercialização – como na modalidade de transportar – é atestada pela exteriorização da conduta do agente, notadamente na forma em que foi flagrado e demais circunstâncias da apreensão da droga.

No caso em tela, a expressiva quantidade de droga apreendida revela, de forma inequívoca, a finalidade do tráfico. As mensagens trocadas com terceiros igualmente indicam a elementar típica. Ainda, o próprio réu confessou que foi "contratado" para transportar a droga.

As substâncias apreendidas foram submetidas à perícia, constatando-se a presença de "tetrahydrocannabinol", substância psicoativa presente na "maconha", causadora de dependência e integrantes da Portaria 344/1998 do Ministério da Saúde (laudo pericial às fls. 101/103 e 139/141).

Por fim, os réus não dispunham de autorização para trazer consigo ou transportar as aludidas drogas.

Logo, considerando a comprovação da autoria e da materialidade, da tipicidade formal e material da conduta, bem como a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação do réu é a medida que se impõe.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, d, do CP, em relação ao réu Gelci Simões.

Ainda, considerando a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça), atestada pela prova oral produzida e notadamente pelas mensagens no aparelho de telefone celular, tudo a evidenciar que a droga saiu do Paraná com destino ao estado de São Paulo, incide a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Por fim, com relação à causa de diminuição de pena do art. 33, parágrafo quarto, entendo que não estão presentes os requisitos para sua aplicação, quais sejam, cumulativamente, agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, 2ª Turma, HC 152001 AgR, em 29/10/2019 e HC 154694 AgR/SP, em 4/2/2020), para fins de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, milita em favor do réu a presunção de preenchimento dos requisitos do parágrafo quarto do art. 33. Para afastar a minorante, pode ser utilizada, desde que apenas em uma das fases da dosimetria, como regra, a quantidade e variedade da droga (STF, plenário, ARE 666634, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral, Tema 712 - As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena -.; STF, 2ª Turma, RHC 122684/MG; STJ, 5ª Turma, HC 329.744/MS e STJ 6ª Turma, AgInt no HC 545.926/SP, julgado em 20/05/2020).

Anoto ainda que há entendimento jurisprudencial no sentido de permitir a utilização concomitante da quantidade de drogas na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, desde que como critério de reforço na comprovação de o réu integrar organização criminosa (STJ, 5ª Turma, AgRG no AREsp 1259578/SP).

Em se tratando de réu primário, é possível utilizar, com análise criteriosa e no cotejo com as demais circunstâncias do caso concreto, a quantidade de drogas como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena.

Para a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 130981/MS, julgado em 18/10/2016, “não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 quilos de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo quarto, da Lei de Drogas”. Já na 2ª Turma, há precedente (RHC 138715/MS, julgado em 23/05/2017) no sentido de que a “quantidade de droga encontrada não constitui, isoladamente, fundamento idôneo pra negar o redutor”.

Como se vê, interpretando-se os precedentes jurisprudenciais, e à luz do caso concreto, a quantidade exorbitante de droga apreendida, transportando drogas entre dois estados, configuram as circunstâncias exigidas pela jurisprudência para afastar a minorante. Ademais, o réu Gelci ostenta condenação pretérita com trânsito em julgado.

Feitas tais considerações, passo a dosimetria da pena.

a) MARY DIANE ALBANO

Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Tóxicos, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, cinco anos de reclusão e 500 dias multa. Deixo de valorar negativamente a quantidade de droga na presente fase, sob pena de bis in idem (filiando-me ao entendimento da 6ª Turma do STJ, Agint no HC 545.926/SP, j. 26/05/2020 e ao Tema 712 do STF, sem a distinção feita pela 5ª Turma do STJ no AgRG no HC 549.034/SP, j. em 09/06/2020).

Na segunda fase, nada a considerar, motivo pelo qual a pena intermediária fica mantida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, conforme exposto na fundamentação, presente a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas (1/6 a 2/3). Considerando que houve a transposição da fronteira entre dois estados, com grande quantidade de drogas, porém sem chegar ao destino, aplico a fração intermediária de aumento de 1/3, tornando definitiva a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Fixo o dia multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo

Em razão da primariedade da ré, do quantum de pena fixado e ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime inicial semi-aberto para cumprimento da pena.

b) GELCI SIMÕES

Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Tóxicos, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, cinco anos de reclusão e 500 dias multa. Deixo de valorar negativamente a quantidade de droga na presente fase, sob pena de bis in idem (filiando-me ao entendimento da 6ª Turma do STJ, Agint no HC 545.926/SP, j. 26/05/2020 e ao Tema 712 do STF, sem a distinção feita pela 5ª Turma do STJ no AgRG no HC 549.034/SP, j. em 09/06/2020).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da

reincidência, que se compensam porque igualmente preponderantes, motivo pelo qual a pena intermediária fica mantida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, conforme exposto na fundamentação, presente a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas (1/6 a 2/3). Considerando que houve a transposição da fronteira entre dois estados, com grande quantidade de drogas, porém sem chegar ao destino, aplico a fração intermediária de aumento de 1/3, tornando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Fixo o dia multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, dado o quantum de pena aplicada e a reincidência do réu.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: a) condenar a ré MARY DIANE ALBANO pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei de Drogas, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, e ao pagamento de 666 dias multa, no dia-multa estabelecido no mínimo legal; b) condenar o réu GELCI SIMÕES pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei de Drogas, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado; c) absolver os réus da imputação do art. 35 da Lei de Drogas nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Incabíveis os benefícios do art. 44 e art. 77 do Código Penal, dada a quantidade de pena aplicada.

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juízo da Execução.

Em atenção ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, observe-se que os réus responderam ao processo presos, nada tendo sobrevivendo no seu curso a alterar o juízo sobre a necessidade da imposição de sua prisão preventiva. Inclusive, com a prolação da sentença resta comprovada a autoria ao passo que nenhum fato superveniente alterou os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Assim, atendendo ainda ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva, pois as circunstâncias do caso concreto – grande quantidade de droga – 260 quilos de maconha, transportada entre estados – recomendam sua manutenção. No caso da co-ré Mary Diane, considerando a condenação em regime semi-aberto, recomende-se, com urgência, o presídio em que se encontra, para adequação da prisão preventiva.

Expeça-se guia de execução provisória.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução definitiva ; e) autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06; e f) decreto a perda dos valores e bens apreendidos em favor da do Funad, com fulcro no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.

Pirapozinho, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA